

刑法
No182

共通問題 H25-17

(配点: 2)

月	日
月	日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、生活費欲しさから強盗を計画し、12歳の長男乙に対し、Vから現金を強取するよう指示した。乙は、甲の指示に従い、Vに刃物を突き付けて現金を強取した。乙が是非善悪の判断能力を有していたか否か、甲の指示により意思を抑圧されていたか否かにかかわらず、甲には強盗罪の間接正犯が成立する。
2. 甲は、通常の判断能力がないVの殺害を計画し、Vに対し、首をつつても仮死状態になるだけであり、必ず生き返るとだまして、Vに首をつらせて窒息死させた。甲には自殺関与罪が成立する。
3. 甲と乙は、自分たちのことを日頃ばかりにするVを懲らしめてやろうと思い、Vに傷害を負わせる旨共謀した。そして、甲と乙は、それぞれ、Vに対し、日頃の恨みを言いながら、その身体を殴り付けた。Vは、これに应答して甲らを罵った。すると、乙は、Vの発言に腹を立て、殺意をもって、隠し持っていたナイフでVを刺し殺した。乙に殺人罪が成立する場合、甲には、Vに対する殺意がなくても殺人罪の共同正犯が成立する。
4. 甲は、V宅に石を投げ付け窓ガラスを割り始めた。これをたまたま見た乙は、自分も窓ガラスを割りたいと思い、甲に気が付かれないよう、V宅に石を投げ付け、甲が割った窓ガラスとは別の窓ガラスを割った。甲と乙には器物損壊罪の共同正犯は成立しない。
5. 女性である甲は、甲の男友達である乙との間で、乙がVを不同意性交する旨共謀した。その後、甲がVを誘い出してVの体を押さえ付け、乙がVを不同意性交した。乙に不同意性交等罪が成立する場合でも、甲には不同意性交等罪の共同正犯は成立しない。(改)

1 誤っている

最決昭 58.9.21 (百選 I 74 事件)。本記述では、親が刑事未成年である子に指示して、子に犯行を行わせた場合、子の是非善悪の判断能力や意思の抑圧の状況にかかわらず、親に間接正犯が成立するかが問題となる。判例は、被告人が、日頃被告人の言動に逆らう素振りを示せる都度暴行を加えて自己の意のままに従わせていた当時 12 歳の養女に対し、窃盗を命じてこれを行わせたという事案において、「被告人が、自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている同女を利用して右各窃盗を行つたと認められるのであるから、たとえ所論のように同女が是非善悪の判断能力を有する者であつたとしても、被告人については本件各窃盗の間接正犯が成立する」としており、被利用者の是非善悪の判断能力、意思抑圧の有無を考慮した上で、被利用者が是非弁別能力を有していた場合は、意思抑圧がなければ間接正犯は成立しないことを示している。

2 誤っている

最決昭 27.2.21。本記述では、殺意をもって、通常の判断能力がない者に対し、首をつつても仮死状態になるだけであり、必ず生き返るとだまして、首をつらせて窒息死させた者は、自殺関与罪の罪責を負うにとどまるのか問題となる。判例は、本記述類似の事案において、殺人罪であつて自殺関与罪ではないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、自殺関与罪の客体は、行為者以外の自然人であるが、死の意味を理解し得る能力と、自由に意思を決定する能力を有することが必要であるということを示している。

3 誤っている

最決昭 54.4.13 (百選 I 92 事件)。本記述では、傷害の意思で共謀をした共犯のうちの 1 人が、犯行中に殺意をもって被害者を殺害し、その者に殺人罪が成立する場合、他の共犯者に、殺人罪の共同正犯が成立するかが問題となる。判例は、上記の問題が争われた事案において、「殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから、暴行・傷害を共謀した被告人 A ら 7 名のうちの B が「前記……〔被害者〕 V に対し未必の故意をもって殺人罪を犯した本件において、殺意のなかつた被告人 A ら 6 名については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立する」としている。その理由として、判例は、「B が殺人罪を犯したということは、被告人 A ら 6 名にとつても暴行・傷害の共謀に起因して客観的には殺人罪の共同正犯にあたる事実が実現されたことにはなるが、そうであるからといって、被告人 A ら 6 名には殺人罪という重い罪の共同正犯の意思はなかつたのであるから、被告人 A ら 6 名に殺人罪の共同正犯が成立するいわれはなく、もし犯罪としては重い殺人罪の共同正犯が成立し刑のみを暴行罪ないし傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪の共同正犯の刑で処断するにとどめるとするならば、それは誤りといわなければならない。」ということを示している。

4 正しい

大判大 11.2.25。本記述では、乙が甲と共同して犯罪を実行する意思をもって犯行に参加したが、甲は乙の参加の事実を知らなかった場合 (片面的共同正犯) に、共同正犯が成立するかが問題となる。判例は、行為者間に意思の連絡を欠くときは、たとえその 1 人が他の者と共同実行の意思をもってその犯罪に参加した場合であっても、共同正犯は成立しないとしている。その理由として判例は、60 条が共同正犯について一部実行全部責任を認める趣旨は、単独正犯と異なり行為者相互間に意思の連絡、すなわち共同実行の認識があり、互いに他の一方の行為を利用しつつ全員が協力して犯

罪事実を発現させる点にあるところ、片面的共同正犯の場合には、全員の協力により犯罪事実を実行したということとはできないということを挙げている。

5 誤っている

本記述では、女性にも不同意性交等罪の共同正犯が成立するかが問題となる。かつての判例（最決昭 40.3.30）は、「強姦罪〔注：不同意性交等罪。以下同じ〕は、その行為の主体が男性に限られるから、刑法 65 条 1 項にいわゆる犯人の身分に因り構成すべき犯罪に該当するものであるが、身分のない者も、身分のある者の行為を利用することによつて、強姦罪の保護法益を侵害することができるから、身分のない者が、身分のある者と共謀して、その犯罪行為に加功すれば、同法 65 条 1 項により、強姦罪の共同正犯が成立する」としていた。けれども、既に平成 29 年改正により行為の主体を男性に限定しなくなっている。それを踏まえた令和 5 年改正の 177 条もまた「前条 1 項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ……『性交等』……をした者は」不同意性交等の罪とするとして、行為の主体を男性に限っていない。そのため、65 条 1 項を論じるまでもなく、女性にも当然に不同意性交等罪の共同正犯が成立する。